

1501422-72.2020.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo Lopes Sardinha

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... tocante ao crime de associação ao tráfico, condenando-o pelo crime de tráfico de drogas.

Requeru ainda, a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, o reconhecimento da atenuante da confissão, o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do CP, o reconhecimento e da causa de diminuição prevista no §4º do artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

2ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

SENTENÇA

Processo nº:

1501422-72.2020.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO HENRIQUE DE ABREU

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Lopes Sardinha

V I S T O S.

GUSTAVO HENRIQUE DE ABREU e LUCAS KOLDEN REINALDO TARDIVO, qualificados nos autos, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006, porque segundo a denúncia 27 de setembro de 2020, por volta de 10h, na Rua José Vieira, nº 381, Conjunto Habitacional Teresa Maria Barbieri, nesta cidade e comarca de Birigui, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em ocasião de calamidade pública.

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço descritas acima, GUSTAVO HENRIQUE DE ABREU E LUCAS KOLDEN REINALDO TARDIVO, guardavam e tinham em depósito 517,29 gramas de maconha, distribuídos em 42 (quarenta e uma) porções, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar¹, em ocasião de calamidade pública.

A denúncia foi recebida às fls. 143/144. O réu Gustavo foi devidamente citado, apresentando resposta escrita à acusação às fls. 247/248. O corréu Lucas não foi localizado para ser citado pessoalmente, razão pela qual os autos foram suspensos, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal e desmembrados em relação a ele (fls. 288 e 320).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos de três testemunhas arroladas pela acusação, interrogando-se posteriormente o réu (fls. 300/301).

Em alegações finais apresentadas oralmente, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência parcial da acusação e, por conseguinte, a absolvição do réu no tocante ao crime de associação ao tráfico, condenando-o pelo crime de tráfico de drogas.

Requeru ainda, a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, o reconhecimento da atenuante da confissão, o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do CP, o reconhecimento e da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, a fixação de regime fechado para o cumprimento da pena, a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou sursis processual.

A defesa, a seu turno, requereu a absolvição do réu. Em caso de condenação pelo crime de tráfico, pugnou o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do CP e do concurso material de crimes, requerendo ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão, a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena, a concessão do direito de recorrer em liberdade e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (fls. 302/308). Juntou documento às fls. 313/315. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido deduzido na presente ação penal é parcialmente procedente, nos termos das razões fáticas e jurídicas adiante alinhadas.

Encerrada a instrução processual penal, a materialidade do delito de tráfico restou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 32/35, auto de exibição e apreensão de fls. 36/37, autos de constatação prévia de entorpecentes de fls. 43/45, laudos de exames químico-toxicológicos de fls. 114/122, laudo pericial objetos de fls. 123/125, bem como pelos demais depoimentos colhidos nos autos.

A autoria, da mesma forma, restou devidamente indubitosa. Vejamos.

Destaca-se inicialmente que o réu confessou a prática do tráfico.

Interrogado em juízo, Gustavo declarou que na época dos fatos estava enfrentando dificuldades financeiras e decidiu vender drogas para sustentar a família.

Indagado, o réu afirmou que o corréu Lucas é seu irmão, acrescentando que ambos residem no mesmo terreno, mas em casas separadas.

Negou vender drogas na companhia de Lucas, alegando que não possuía amizade com o irmão. Ao ser questionado, o réu afirmou ter iniciado a traficância no ano de 2019, acrescentando trabalhar como servente de pedreiro.

Por sua vez, o policial Douglas Vinícius Pereira narrou que no dia dos fatos foi acionado via Copom para atender uma ocorrência de violência doméstica e ao chegar à residência do casal, visualizou uma balança de precisão na cozinha e questionou a vítima acerca do objeto, a qual revelou que a balança pertencia ao companheiro Gustavo.

O depoente ainda narrou: "...Fui lá e perguntei pra ele. Ele falou: Realmente eu to fazendo o tráfico de entorpecentes junto com meu irmão Lucas [...] Aí eu falei que ia procurar. Aí na geladeira nós localizamos uma parte do entorpecente e no quarto das três crianças estava o restante da droga, fracionados em uma mochila em cima da

porta. Aí a Alessandra falou que não tinha com quem deixar as crianças para ir à delegacia e tenho que deixar com a minha cunhada, mas eu to chamando e ela não tá atendendo. Aí fomos lá na casa, batemos no portão e a cunhada saiu. Perguntamos se tinha droga na residência dela, ela falou que não sabia, mas permitiu nossa entrada. Localizamos o Lucas deitado no colchão na sala e perguntamos pra ele. Ele falou que tinha entorpecente e que estaria dentro do guarda roupa e que a gente poderia entrar e pegar. Fomos lá e localizamos o entorpecente”.

Ao ser questionado, o depoente relatou que Gustavo confessou a prática do tráfico, acrescentando que o réu colaborou com o serviço policial. Por fim, declarou que não conhecia o réu dos meios policiais, revelando que Gustavo confirmou ter adquirido droga em sociedade com o irmão.

Em seu depoimento, a testemunha Alessandra Dutra narrou: “Eu cheguei do trabalho e vi uma balança de precisão na cozinha e começamos a brigar. Aí ele ameaçou e eu chamei a polícia. A briga começou por causa disso. Eu nunca autorizei ele vender drogas, eu já tinha brigado com ele por causa disso, aí a polícia achou outras coisas [...] mais ou menos uns seis meses (sobre ter brigado com Gustavo anteriormente por causa de droga) [...] A gente tava numa situação complicada e só fazia bico e então ele se sentia pressionado, até talvez por mim”.

Indagada, a testemunha declarou que no ano anterior aos fatos o réu trabalhava formalmente.

Pois bem. Conforme sobressai do conjunto probatório, não restam dúvidas que Gustavo guardava e mantinha em depósito, a substância entorpecente para fins mercantis. No caso vertente, a confissão judicial restou plenamente corroborada pelos depoimentos da esposa do réu e dos policiais militares que atuaram na ocorrência. De fato, os policiais militares prestaram depoimentos uníssomos e fizeram suas declarações com convicção narrando os fatos de forma veemente.

Referidos depoimentos, cabe ressaltar, têm valor probatório idêntico àquele prestado por outras pessoas, notadamente se em sintonia com as demais provas produzidas, como é o caso dos autos.

É ilustrativo o escólio jurisprudencial adiante colacionado, do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“PROVA – Testemunha – Policial – Revestindo-se de inquestionável eficácia o depoimento de servidores policiais, não se pode desqualificá-lo por emanar de agente estatal incumbido da repressão penal, circunstância que não afeta positiva ou negativamente o valor de sua palavra – Recurso não provido.” (Apelação Criminal n. 990.08.040006-1 – Limeira – 16ª Câmara de Direito Criminal – Relator: Newton Neves – 10.02.09 – V.U. – Voto n. 6224).

Sendo ainda entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal: “É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.” (...) STJ - HC 76.557-RJ 2ª T., rel Carlos Velloso, 04.08.1998.

Vale ressaltar que, para fins de reconhecimento do delito, desnecessária a comprovação da venda efetiva do entorpecente. A quantidade e a forma de acondicionamento são suficientes para a conclusão de existência de crime de tráfico de entorpecente.

Nesse entendimento, para a configuração do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, basta o ato de “Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação

legal ou regulamentar", não se exigindo o ato de mercancia.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Réus detidos na posse de papérolas de cocaína - Quantidade e acondicionamento da droga evidenciando o comércio ilícito - Credibilidade, ademais, do testemunho dos policiais que fizeram a apreensão - Recurso parcialmente provido" (Apelação Criminal n.º 180.224-3 - São Paulo - Relator: GONÇALVES NOGUEIRA - CCRIM 3 - v.u. - 03.04.95).

Ainda, importante mencionar as circunstâncias da apreensão, fundamentais a atestar a finalidade mercantil dos entorpecentes. No caso concreto, a quantidade da droga apreendida (335.89 gramas de maconha e 0.88 gramas de sementes da mesma droga), a forma de acondicionamento (29 porções), a presença de petrechos comumente utilizados para fracionar, pesar e embalar drogas (faca, balança de precisão e invólucros plásticos), evidencia o destino mercantil das substâncias entorpecentes.

Outrossim, não se pode ignorar que Gustavo confessou a a traficância por enfrentar dificuldades financeiras, tornando a autoria delitiva certa e inquestionável. Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio, na obra "Legislação Penal Especial", ed. Atlas, 2ª edição, p.122, ensinam: "Ressalte-se, porém, que a comprovação elementar do tipo previsto no art. 16 - uso próprio - nem sempre é de fácil constatação, prevendo a própria lei, em seu art. 37, alguns critérios legais. Assim, para efeito de caracterização das condutas criminosas previstas na Lei nº 6.368/76, deverão ser analisados a natureza e quantidade da substância apreendida, o local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Deve, igualmente, ser levada em conta para efeito de tipificação do delito a forma de acondicionamento da substância entorpecente.".

Por outro lado, o conjunto probatório não demonstrou a existência de uma verdadeira associação para o tráfico.

Com efeito, para a caracterização daquela infração penal é imprescindível a prova da estabilidade e permanência, o que distingue o crime autônomo do mero concurso de agentes.

Vale mencionar que o fato dos réus terem sido surpreendidos com droga em suas residências que se situam no mesmo terreno e serem irmãos, não é suficiente para daí se concluir pela existência de uma associação para o tráfico.

Nesse sentido é a jurisprudência:

"TÓXICOS - Tráfico - Associação criminosa - Não configuração - Inexistência de elementos que demonstrem o vínculo associativo entre os três acusados - A prova aponta no sentido de que os réus estavam juntos para a prática do crime, mas não permite afirmar que havia, entre eles, vínculo permanente, duradouro, de modo a permitir tal condenação - Impossibilidade de caracterização do delito autônomo - Hipótese que comporta a absolvição dos recorrentes pelo crime tipificado no artigo 35 da Lei n. 11.343/06 - Recurso parcialmente provido neste aspecto." (Apelação Criminal n. 993.08.040835-1 - São Paulo - 5ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Pinheiro Franco - 31.07.08 - V.U. - Voto n. 10.992).

"TÓXICOS - Tráfico - Associação criminosa - Inexistência de prova da estabilidade na associação para a prática do comércio de entorpecentes, não se sabendo se os agentes teriam agido anteriormente, mesmo em passado recente, com essa finalidade - Condenação pelo crime previsto no art. 14 da Lei n. 6.368/76 - Impossibilidade - Consideração da comparsaria como mera agremiação eventual, que, apesar de não mais

ser tratada como causa de aumento de pena pela Lei n. 11.343/2006, serve de critério valorativo na gradação do índice de redução previsto no § 4º do art. 33 desse último diploma legal – Admissibilidade – Recursos parcialmente providos para absolver os apelantes da imputação prevista no art. 14 da Lei n. 6.368/76, com fundamento no art. 386, inciso VI, do CPP, e, no tocante ao art. 12 da mesma lei, reduzir as penas privativas de liberdade, fixando-se o regime inicial fechado.” (Apelação Criminal n. 1.019.227.3/2-0000-000 – São Paulo – 11ª Câmara Criminal – Relator: Silveira Lima – 06.06.07 – V.U. – Voto n. 11.517).

Vê-se, portanto, que o conjunto probatório aliado à confissão do réu e aos depoimentos dos policiais militares, torna certa e inquestionável a materialidade e autoria delitivas pelo crime de tráfico, pelo que um decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo, pois à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida (335,89 gramas de maconha e 0,88 gramas de sementes da mesma droga), recomendam a exasperação da pena base. Dito isso, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, reapreciando entendimento anterior adotado por esse juízo, incabível a agravante prevista no art. 61, inc. “j”, do Código Penal, eis que não restou devidamente comprovado nos autos que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretada em virtude da pandemia do COVID-19.

Nesse mesmo entendimento: "APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa pretende a redução da pena, afastamento da agravante do delito praticado durante a pandemia do COVID-19, compensação das atenuantes com a recidiva e o abrandamento do regime prisional. Parcial acolhimento. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas sequer foram objeto do recurso defensivo. Prisão em flagrante. Réu confesso. Seguro relato das testemunhas descrevendo a dinâmica criminoso e imputando ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Condenação inevitável. Dosimetria comporta reparos. Na segunda etapa, necessário afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal. Da mesma forma, imperioso compensar as atenuantes da confissão e da menoridade relativa com a agravante da reincidência. Súmula 545 do E. STJ. Impossível a concessão do privilégio. Regime fechado decorre de expressa determinação legal e foram devidamente fundamentados nos autos. Súmulas nº 718 e 719 do C. STF e 440 do e. STJ. Inviável a substituição por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido" (TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1512067-20.2020.8.26.0228, Rel. Des. Andrade Sampaio, v.u., j. 12.02.2021). Contudo, não se pode ignorar que o réu confessou a prática do crime, devendo incidir a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, do CP, de modo que retorno a reprimenda ao mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porquanto o réu é tecnicamente primário e não há provas de que integre organização criminosa, anotando que a quantidade de entorpecentes foi sopesada na primeira fase, não sendo possível considera-la novamente a fim de afastar o redutor, sob pena de bis in idem. Nesse passo, diminuo a reprimenda em 1/6, perfazendo 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, eis que o tráfico de entorpecentes se trata de ilícito penal equiparado aos crimes hediondos. Por

identidade de razões, incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por incompatibilidade lógica.

O réu poderá recorrer em liberdade eis que respondeu ao processo solto.
Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido por meio da presente ação penal para:

- a) CONDENAR GUSTAVO HENRIQUE DE ABREU, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, cujo valor unitário fixo no mínimo legal, ante a ausência de provas de que o réu possui boas condições financeiras.
- b) ABSOLVER GUSTAVO HENRIQUE DE ABREU qualificado nos autos, da prática do delito previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado e o réu poderá recorrer em liberdade, eis que respondeu ao processo solto (Cf. fls. 167/169).
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.

Anoto que eventual detração da pena deverá ser deduzido perante o juízo competente, qual seja, a vara das execuções criminais. Transitada em julgado a presente decisão, comunique-se a Justiça Eleitoral para os fins previstos no art. 15, III, da CF. A determinação da incineração da droga já foi concluída, nada havendo a ser deliberado. (fls. 238).

Não tendo o réu demonstrado a procedência lícita dos objetos apreendidos (fls. 36/37), conclui-se que se tratam de instrumentos e produtos do tráfico de entorpecentes por ele praticado, razão pela qual decreto o perdimento, com fundamento no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e 63 da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao "SENAD" quanto ao perdimento supradeterminado, instruindo o ofício com cópias do auto de exibição e apreensão, da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, o disposto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

P.R.I

Birigui, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA